

正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、乙が甲所有の自動車を盗むのを目撃し、これを追跡したものの見失い、その翌日、窃取された場所から約2キロメートル離れた路上で、乙がその自動車から降りて立ち去ったのを認めた。甲は、乙がすぐに戻って来る様子であったので、直ちにその自動車を運転し、自宅に戻った。この場合、甲には正当防衛が成立する。
2. 甲は、散歩中、仲の悪かった乙から大型犬をけしかけられたので、犬から逃げようとして、偶然その場を通り掛かった丙を突き飛ばして走り去った。甲の行為により、丙は転倒して全治約1週間を要する足首捻挫の傷害を負った。この場合、甲には正当防衛が成立する。
3. 甲は、乙ら数名の男によって監禁されたが、監禁されて2週間後、たまたま見張りが乙一人になったので、監禁場所から脱出するため、乙の顔面を1回殴打して乙がひるんだ隙にそこから逃げた。この場合、甲には正当防衛が成立する。
4. 甲は、深夜、路上で、見知らぬ乙から、ナイフを胸元に突き付けられ現金を要求されたので、ナイフを避けるために乙の胸付近を手で押し、走って逃げ出した。甲の行為により、乙は転倒した後頭部を路面に打ち付け、全治約1か月間を要する頭部打撲の傷害を負った。この場合、甲には正当防衛は成立しない。
5. 甲は、同居していた乙と言い争いをし、乙から「ぶっ殺すぞ。」と怒鳴られたため、身の危険を感じて一旦家を出たが、乙と仲直りをしようと考え直し、乙から暴力を振るわれることがあるかもしれないと思いつつ、家に戻って乙に謝罪した。しかし、甲は、乙に数回顔面を殴られた上、更に殴り続けられそうになったことから憤激し、とっさに乙の脇腹付近を1回蹴り、乙に全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負わせた。この場合、甲には正当防衛は成立しない。

No.82	正当防衛	正答率
予備H23-1	正 解	88%
	3	

1 誤っている

最判昭 46.11.16。判例は、「刑法 36 条にいう『急迫』とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることを意味」するとしている。この定義からは、過去の侵害、過ぎ去った侵害には防衛行為はできないということが導かれる。本記述では、甲は乙による窃盗行為の際、同人を追跡したものの見失い、その翌日に乙が同自動車から降りて立ち去ったのを認めている。窃盗罪は状態犯であるから、乙が甲の自動車を盗んだ時点で、犯罪が成立し、犯罪成立と同時に終了するため、甲が乙に盗まれた自動車を運転した時点においては、乙による窃盗行為は過去の侵害といえ、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っているとはいえない。よって、「急迫」の要件を欠くため、甲が自動車を運転し自宅に持ち去ったことについて、甲に正当防衛は成立しない。

2 誤っている

正当防衛は、被害者に対する侵害を正当化するものであり、被害者以外の第三者に生じた法益侵害を正当化するものでないとして解されている。その理由として、学説は、正当防衛は、「急迫不正の侵害」者の法益に対する、被害者の法益の質的な優位性を違法性阻却の根拠とするものであるという点を挙げている。本記述では、甲は、偶然その場を通り掛かった、被害者以外の第三者である丙を突き飛ばしているため、この甲の行為について、正当防衛は成立しない。

3 正しい

最判昭 46.11.16。判例は、「刑法 36 条にいう『急迫』とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることを意味」するとしている。監禁罪は継続犯であり、結果が継続する間、犯罪が継続的に成立するため、監禁されている甲に対する侵害は現在しているから「急迫不正の侵害」(36 条 1 項)の存在は認められる。また、甲は監禁場所から脱出するために暴行を行っているから「防衛するため」(36 条 1 項)の要件も認められる。更に、甲は 2 週間という長期にわたり監禁されており、その法益侵害の程度は重大であるのに対して、甲の行為は乙の顔面を 1 回殴打したというものにすぎず、必要かつ相当な行為といえるため、「やむを得ずにした行為」(36 条 1 項)といえる。よって、甲には正当防衛が成立する。

4 誤っている

最判昭 44.12.4。判例は、「刑法 36 条 1 項にいう『已むことを得ざるに出てたる行為』とは、急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味するのであって、反撃行為が右の限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではないと解すべきである」としている。本記述では、ナイフという凶器を胸元に突きつけた上で現金を要求するという乙の侵害行為は甲の身体への安全への高度の危険性を有する行為であるのに対して、甲の行為は乙の胸付近を手で押したという軽微なものにすぎない。そうだとすれば、結果として乙は全治約 1 か月間を要する頭部打撲という傷害を負っているものの、甲の反撃行為は、自己の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであるといえるため、甲の行為は相当性の範囲内にあり「やむを得ずにした行為」といえる。よって、甲には正当防衛が成立する。

5 誤っている

最判昭 46.11.16。判例は、「『急迫』とは法益の侵害が現に存在しているか、または、間近に押し迫っていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失うものと解すべきではない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、正当防衛は「不意打ち」により正しい判断・行為をなしがたい状況下で行った違法行為について責任阻却を認めることを内容とする責任阻却事由ではないから、「不意打ち」による意思の抑圧はその成立要件とはならず、侵害の急迫性を肯定するためには、法益侵害の客観的な急迫性が存在することで足りるということを挙げている。よって、甲が事前に乙による暴力を予想していたことをもって「急迫」性を欠くこととはならない。また、判例は、「刑法 36 条の防衛行為は、防衛の意思をもってなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきでない」とした上で、「攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情が認められないかぎり、被告人の反撃行為は防衛の意思をもってなされたものと認めるのが相当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、憤激・逆上しただけで防衛の意思の存在を否定し、攻撃の意思があると防衛の意思を認めないのでは、防衛の意思が実際上ほとんどの場合に否定されることになりかねず、正当防衛という制度を事実上骨抜きにすることになることを挙げている。本記述では、甲は乙から更に殴り続けられそうになったことに対応するために攻撃を加えており、乙から攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情も認められないから、防衛の意思が認められる。また、甲は顔面を殴打されるという乙の侵害行為に対して、乙の脇腹付近を 1 回蹴ったにすぎず、甲の行為は「やむを得ずにした行為」といえる。よって、甲には正当防衛が成立する。